

1500181-81.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500181-81.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500181-81.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER PAULO DA ROCHA

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual KLEBER PAULO DA ROCHA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 116/122) que, entre os dias 11 de janeiro de 2022 e 18 de janeiro de 2022, na Avenida Sarah Veloso, na via pública, altura do nº 652, Veloso, nesta cidade e Comarca de Osasco, KLEBER PAULO DA ROCHA, qualificado a fls. 05, recebeu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de IMEI 354291422675667, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo se apurou, o celular em tela, de propriedade da vítima Iria Rossi da Costa, fora furtado no dia 11 de janeiro de 2022, consoante boletim de ocorrência eletrônico nº 78464/2022 (fls. 10/12).

Em data incerta, mas entre os dias 11 de janeiro de 2022 e 18 de janeiro de 2022, o denunciado recebeu o mencionado aparelho celular, de pessoa não identificada e em circunstâncias não esclarecidas, sabendo, no entanto, de sua origem ilícita.

Na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o denunciado em atitude que julgaram suspeita, posto demonstrar apreensão, motivo pelo qual foi abordado.

Na oportunidade, os agentes da lei localizaram, na posse do denunciado, o aparelho celular em tela, que, através de pesquisa pelos IMEI, indicou ser objeto de furto.

O denunciado tinha ciência da origem espúria do bem, uma vez que, qualquer que tenha sido a circunstância em que recebera o objeto, o fez sem o acompanhamento de qualquer documento que comprovasse sua licitude.

É dos autos que o denunciado ostenta inúmeras incursões à Justiça Criminal por delitos patrimoniais diversas, contando, inclusive, com diversas condenações, consoante certidão de fls. 23/33 e FA de fls. 34/64.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02.

Auto de exibição e apreensão às fls. 06.

Fotografia do celular apreendido às fls. 13/14.

Certidão de distribuição criminal e folha de antecedentes às fls. 23/64 e 136/169.

Em sede de audiência de custódia (fls. 79), foi concedida liberdade provisória ao acusado cumulada com medidas cautelares diversas (fls. 70/73). Alvará de soltura cumprido às fls. 82/84.

Auto de entrega às fls. 93.

A denúncia foi recebida às fls. 124/127.

Citado (fls. 174), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, às fls. 177/178. Não foi suscitada qualquer questão preliminar e, quanto ao mérito, reservou-se, a Defesa, o direito de se manifestar em momento oportuno.

Em decisão de fls. 181/183, foi mantido o recebimento da denúncia, mesma oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento virtual para o dia 03 de outubro de 2022, às 16h20min.

Em audiência forma ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu interrogado.

Em debates, a Acusação pediu a procedência nos termos da inicial.

Em debates, a Defesa pediu a absolvição por ausência de provas. Sustentou que a abordagem foi ilegal, eis que não haveria evidência de se tratar de crime permanente ou mesmo de comportamento do acusado que justificasse a diligência. Sustentou que o nervosismo não é inusual ainda mais porque o acusado já teria sido abordado anteriormente. Não havia motivo objetivo para a abordagem. Também sustentou a ausência de dolo. Pena mínima e regime aberto.

É relatório.

Fundamento e decido

I - Valoração racional da prova

Com efeito, encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-

probatória não é suficiente à demonstração da conduta penal na dimensão subjetiva, para além da dúvida razoável, devendo, portanto, prevalecer a postulada da presunção e inocência pelos motivos que passo a expor.

Compulsando os autos, não há minimamente elementos de prova que apontem para a existência do elemento subjetivo do autor do fato. O contexto não demonstra que o réu tenha recebido o aparelho celular ciente de sua origem ilícita.

Os policiais confirmam que estavam estacionados cumprindo “ponto de visibilidade” e, tendo em conta que o réu apresentou “nervosismo” resolveram abordá-lo. Com o réu nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao consultarem o IMEI, verificaram ser o celular objeto de ilícito. Por este motivo levaram-no para delegacia.

A vítima Iria, sobreleva salientar, confirmou o furto do celular, o que comprova a materialidade delitiva, consoante, inclusive, B.O de fls. 10/12.

Anote-se, de proêmio, ao contrário do que afirma a acusação, que não é razoável exigir que a pessoa apresente nota fiscal ou mesmo que, antes da aquisição de um celular, consulte o IMEI.

No tocante a nota fiscal, a depender do tempo de existência do aparelho, é possível que tal documento sequer exista, até porque tal documento, em regra, é guardado pelo consumidor pelo tempo da garantia do produto. E mais, a demonstrar a falibilidade do argumento, até mesmo dos próprios agentes públicos encarregados da persecução penal não é possível exigir-se a apresentação de notas fiscais dos aparelhos que utilizam pois é possível que não mais as possuam. Assim, não se pode exigir a existência de nota fiscal como critério absoluto de atribuição do dolo direto do tipo do art. 180 “caput”.

No tocante a consulta do IMEI, também não é possível se exigir tal providência, até porque tal ferramenta não fica disponível indistintamente a todos particulares, sem contar, outrossim, que, para a conformação do tipo penal, dever-se-ia presumir que todas as pessoas, independentemente formação e classe social, tenham ciência que seria possível a consulta do IMEI, o que se sabe não é.

Nessa toada, ao contrário do que afirma a acusação, não é possível impor a qualquer pessoa o dever de comparecer a uma delegacia de polícia ou a uma base da polícia militar para verificar se o bem possui ou não origem ilícita até porque, por consequência lógica, a aquisição e negociação precedem a qualquer tipo de consulta.

Por outro lado, conforme se extrai da leitura da denúncia, a acusação imputa ao o denunciado tinha ciência da origem espúria do bem, uma vez que, qualquer que tenha sido a circunstância em que recebera o objeto, o fez sem o acompanhamento de qualquer documento que comprovasse sua licitude.

Pela descrição do Ministério Público e de acordo com a prova produzida, inclusive levando em conta o que relatado pelos policiais, os elementos indicariam, quando muito, o crime de receptação culposa, pela inobservância dever objetivo cuidado de verificação da existência de nota fiscal, entretanto, por ausência de aditamento da inicial, não é possível eventual decreto de condenação, pois haveria ofensa ao princípio da correlação.

Destarte a acusação, em verdade, presume o dolo do agente a partir do fato de que o réu teria “recebido” – esse é o núcleo típico da conduta imputada – o telefone celular de terceira pessoa sem a apresentação de nota fiscal.

Ocorre que tais elementos, por si sós, não bastam para demonstrar o dolo do sujeito na espécie, eis que não são aptos a conduzir à conclusão de que o acusado teria efetiva consciência acerca da “origem espúria” do bem. O contexto, mais uma vez,

não é capaz de trazer elementos substanciais aptos a atribuir o dolo ao sujeito.

Dessa forma, não há, nos autos qualquer elemento que aponte para a existência de dolo do acusado, na dimensão de consciência e vontade, na conduta que lhe é imputada na inicial acusatória (aquisição de coisa sabendo ser produto de crime), sendo certo que tal elemento subjetivo não pode ser, repita-se, presumido em seu desfavor.

Para arrematar, cumpre reforçar que não se admite no Direito Penal Brasileiro a figura da responsabilidade penal objetiva (art. 18 do Código Penal), de modo que incumbe à Acusação demonstrar, por meio de provas valoráveis objetivamente, o elemento subjetivo do sujeito, sob pena de restar inviabilizada a persecução penal.

Ademais, em arremate, a versão apresentada pelo acusado de que seu filho é quem comprou o celular pela quantia de R\$ 600,00 reais no facebook e o aparelho teria sido entregue na estação de Osasco não é de todo inverosímil ainda mais levando-se em conta que fatos como tais já tramitaram por este Juízo, o que demonstra não o dolo direto da ciência ilícita, mas a falta de cautela na aquisição do celular.

Por fim, anote-se que a própria abordagem do réu se reveste de ilegalidade e subjetivismo tendo em conta que, em primeiro lugar, nada de ilícito fora encontrado com o réu e, em segundo lugar, o simples nervosismo, sem qualquer elemento concreto, não é suficiente para concreção do standard probatório exigido pela lei - fundada suspeita - até porque não é incomum a qualquer pessoa - ainda mais em bairro periférico apresentar certo nervosismo diante de uma viatura policial ou mesmo de policiais armados (STJ - HC 659689-DF - Rel. Min. Sebastião Reis Junior - j. 15.06.2021 - 6ª T - Dje 18.06.2021). Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos. 2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do Acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ, REsp 1961459/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Data de Julgamento 05/04/2022, Dje 08/04/2022)

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria (ou presunções). A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido concreto em contraditório judicial. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Anoto, derradeiramente, que este juízo julga fatos praticados por pessoas e não pessoas independentemente de fatos. Assim, o fato do réu ter sido condenado em outro juízo, por outro Magistrado, não é suficiente (e não pode ser) para que este Magistrado interprete e valora os fatos de modo não racional-objetivo, mas sim de forma subjetiva, o que muito se aproximaria de um direito penal de autor, o qual, por essência, é antidemocrático. A condenação por outro juízo não gera presunção de culpa nestes autos.

Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e ABSOLVO o acusado KLEBER PAULO DA ROCHA da acusação de ter infringido o artigo 180, caput, do Código Penal.

P.R.I.C.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Osasco, 05 de outubro de 2022.